

1501532-02.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... trazendo consigo drogas, em evidente situação de tráfico, legitimando sua prisão em flagrante e a atuação da Guarda Civil Municipal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico PRIVILEGIADO. Preliminar. Alegação de ilicitude da prova obtida por apreensão realizada por guardas municipais. Inocorrência. Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí - SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501532-02.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501532-02.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 17h10, na Rua Lúcia Rodrigues Bertin, nº 145, Vila Angélica, nesta cidade e comarca de Tatuí, trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, consistentes em 10 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 08 gramas, e outras 541 porções também de cocaína, com peso bruto aproximado de 460 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por decisão proferida em sede de audiência de custódia, em 20 de novembro de 2022, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 43/45). O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 124/126). A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2022 (fls. 141/142). Durante a audiência (fls. 160/163) foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, passou-se aos debates de forma oral, tudo conforme mídia armazenada em cartório. Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO, o qual, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediu o preceito primário da norma penal incriminadora inserida no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados, impondo-se o acolhimento da pretensão punitiva com a condenação do acusado.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito está comprovada através do auto de prisão em flagrante de fl. 04, boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fl. 10, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 11, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 149/152, entre outros, bem como pela prova oral colhida.

De igual modo, a autoria é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise das provas colhidas nos autos, notadamente as que foram produzidas em audiência e sob o crivo do contraditório. Durante a instrução, a testemunha JUCEIL BATISTA RODRIGUES, guarda municipal, narrou que durante patrulhamento foram informados sobre uma residência que estava sendo utilizada para a prática de tráfico de drogas, onde morava uma pessoa conhecida por “alemão”, indicando o endereço do réu (Rua Lúcia Rodrigues Bertin, 145). Chegando na rua, viram um indivíduo “fazendo menção” de entregar algo a uma motocicleta. Contudo, com a aproximação da viatura, a moto saiu em alta velocidade, ficando apenas o averiguado. Abordado, com ele foram encontradas 10 porções de uma substância embalada a vácuo similar a cocaína e R\$ 60,00 em dinheiro. Indagado sobre a mercancia ilícita, com a ressalva de que recaía sobre ele denúncia nesse sentido, o acusado confessou o crime e afirmou que dentro de sua casa teria mais entorpecentes. Narrou o guarda municipal que o próprio réu franqueou a entrada em sua residência e mostrou onde estava o restante da droga (na gaveta da cômoda do quarto), que totalizava 541 porções, e mais R\$ 1.390,00 em dinheiro dentro de uma sacola plástica. Em seguida, a esposa do averiguado chegou e contou que havia um filho. Às reperguntas da Defesa, contou que foi a primeira vez que abordou o réu, mas que outros colegas já o tinham apontado, dizendo que seria o “alemão” e estaria envolvido com o tráfico na região. Relatou, ainda, que, no momento em que estavam entrando na residência do réu, a esposa dele chegou. Então, conversaram com ela, coletaram dados e a assinatura dela em um documento oficial. Em seguida, ambos acompanharam a apreensão da droga, cuja localização foi indicada pelo próprio acusado (depoimento captado por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011).

A guarda municipal RENATA ROSA RODRIGUES, ouvida em juízo, ratificou na íntegra o depoimento de seu parceiro Juceil, acrescentando, ao ser indagada sobre a autorização para entrada na residência do acusado, que a esposa do acusado assinou um documento franqueando a entrada e esses papéis encontram-se arquivados na sede da guarda municipal, podendo ser requeridos a qualquer momento (depoimento captado por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011).

Por sua vez, o réu JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO, durante seu interrogatório judicial, ouvido sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, inicialmente respondeu que já foi processado anteriormente por furto e porte de arma, mas por tráfico é a primeira vez. Disse que, à época da sua prisão, estava desempregado,

morando com sua esposa e filho. Sobre os fatos, relatou que estava no bar, jogando bilhar com um amigo, quando viu a viatura passar e ir até sua residência, onde estava apenas o seu filho, pois a esposa se encontrava no vizinho. Afirmou que eles adentraram na casa assim mesmo. Em seguida, a esposa voltou. Ressaltou que permaneceu observando tudo de onde estava. Quando decidiu ir até a residência, eles já estavam com a "sacolinha de droga em cima do baú" (sic). Nega, contudo, tenha havido abordagem pessoal e apreensão de entorpecentes em seu poder. Questionado sobre as substâncias ilícitas e o dinheiro apreendidos em sua casa, disse que estava guardando a pedido de um conhecido, identificado pelo apelido de "falcão", que teria lhe dado dinheiro para tanto (interrogatório captado por meio de sistema audiovisual, conforme Provimento CGJ nº 08/2011).

Pois bem. Finalizada a instrução, diferentemente do quanto aduzido pela Defesa, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito a ele atribuído na denúncia; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito.

As porções de drogas encontradas em poder do acusado e em sua residência, as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações dos guardas municipais evidenciam a finalidade de tráfico.

De se ressaltar que o réu além de trazer consigo 10 porções de cocaína armazenadas de forma pronta para o consumo, ainda guardava em sua residência outras 541 porções igualmente embaladas e individualizadas. Junto com ele foi encontrado R\$ 60,00 em notas e, na casa, com o restante da droga, havia mais R\$ 1.390,00, tudo a indicar o comércio ilegal.

Outrossim, a mera negativa do réu no tocante à mercancia ilícita não merece prosperar e não se presta a influir no convencimento deste magistrado, porquanto vem de encontro ao quanto colacionado nos autos, não havendo qualquer elemento que fomenta a sua versão. A afirmação de que apenas guardava a droga para um conhecido e que a quantia de R\$ 1.390,00 já estava no pacote chega a ser pueril e inverossímil.

Ademais, ainda que se pudesse considerá-la, vale lembrar que o crime do tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, e a simples ação de "guardar" drogas, ainda que gratuitamente, configura o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu afirmou, ainda, que teria recebido valores para tanto.

Já no tocante à alegação da defesa de que houve irregularidade no flagrante, com entrada forçada na residência do acusado, imperioso destacar que os guardas afirmaram que a entrada foi autorizada, existindo inclusive um documento público arquivado na sede da GCM que confirma tal fato.

Não obstante, de se ressaltar que não há qualquer óbice à realização de prisões em flagrante por guardas municipais. Chegaria a ser surreal a ideia de que, qualquer indivíduo, ao visualizar a ocorrência de um crime, pudesse efetuar a prisão em flagrante, mas que guardas civis assim não pudessem agir.

A respeito da legalidade da prisão em flagrante por guardas municipais, cumpre transcrever parte do acórdão da lavra do i. des. Lauro Mens de Mello, que de maneira brilhante, como de costume, esgota o tema:

"Importante discutir para que se evite eventual alegação acerca do poder de polícia dos guardas civis. O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal preceitua que: 'A segurança pública, dever do Estado, direto e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: § 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei'. Logo se verifica que a Constituição Federal não retira dos membros da Guarda Civil Municipal a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, inclusive em situações análogas às da espécie, qual seja, prender em flagrante e acompanhar a mercancia de drogas. Ademais, o Estatuto dos Guardas municipais (Lei nº 13.022/14) trata da possibilidade de patrulhamento preventivo (artigo 3º, III) e da colaboração integrada com os demais órgãos de segurança pública (artigo 5º, IV). Portanto, lhes foi conferido poder de polícia, o que legitima tal atuação. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'Outrossim. especificamente quanto aos guardas civis,

incide a inteligência da Lei n. 13.022/14 que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ'. Assim, não há que se falar em ilicitude da prisão efetuada pelos guardas municipais, vez que estavam corretamente cumprindo com seu dever legal. 'Last but not least', estando o réu em situação de flagrância, possível sua prisão por qualquer do povo, por óbvio, também o guarda municipal." (TJSP; Apelação Criminal 1516484-50.2019.8.26.0228; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020). Neste sentido, é a jurisprudência do C.STJ: "A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social" (STJ HC129932/SP, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, j. 15.12.2009).

Desta feita, no entendimento deste juízo não há se falar em irregularidade da prisão ou mesmo apreensão das drogas, já que não houve violação a qualquer preceito constitucional ou abrigado em Lei.

Ora, os guardas civis municipais, no momento em que detectaram o estado flagrancial, eis que o réu trazia consigo substância entorpecente destinada a entrega a terceiros, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Constituição a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF).

Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções.

Deveras, consoante mencionado alhures, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa.

Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento acima exposto.

In casu, o acusado foi surpreendido trazendo consigo drogas, em evidente situação de tráfico, legitimando sua prisão em flagrante e a atuação da Guarda Civil Municipal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico PRIVILEGIADO. Preliminar. Alegação de ilicitude da prova obtida por apreensão realizada por guardas municipais. Inocorrência. Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais. Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei nº 13.022/14. Precedentes. Preliminar rejeitada. Mérito. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Circunstâncias da apreensão que evidenciam a dedicação do acusado à mercancia ilícita. Validade dos depoimentos dos agentes públicos. Negativa de autoria que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Pena, regime e substituição da sanção corporal que não comportam alteração, dados os conformismos da defesa e da acusação. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1509165-26.2022.8.26.0228; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022).

Vale mencionar que nenhuma restrição merece os depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e prisão do acusado, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada acerca de suas condutas.

Nesse sentido:

"... nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória."

(Ap.Crim. 103.701 TJSP);

"... a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64);

"... não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Assim, o quadro probatório é, pois, eficaz e conclusivo em relação à materialidade e autoria dos fatos narrados.

Assim, devem prevalecer os depoimentos dos agentes de segurança, os quais foram claros, congruentes e verossímeis, bem como possuem correlação com a narrativa exposta na denúncia.

Não é crível entender que, no exercício de suas funções, guardas municipais atuem com a intenção deliberada e desarrazoada de incriminar pessoas pela prática de ilícitos dos quais não são responsáveis.

Disso, em prestígio à prova testemunhal, a qual está amparada pelos elementos coligidos na fase extrajudicial, não é caso de entender pela ilicitude da prova obtida e a pleiteada improcedência da ação penal.

Em suma, a convicção deste juízo é a de que a Defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento que fosse capaz de, ao menos, colocar em dúvida algum ponto do acervo probatório constituído nestes autos, o qual se revela farto e demonstra com riqueza de detalhes toda a ação delituosa. Os argumentos expostos em sede de memoriais não possuem força bastante para infirmar os argumentos fáticos e jurídicos veiculados na denúncia.

Inconteste, pois, a ocorrência de todos os elementos típicos, subjetivos e objetivos, necessários para a responsabilização do réu pela prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Adotando-se o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, observando, ainda, a Lei n. 11.343/06, atual Lei de Drogas, passo à fixação da pena.

Na primeira fase do critério trifásico, atento ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu ostenta duas condenações definitivas, caracterizando, uma delas, como Maus Antecedentes (fls. 28/30 - processo nº 0002771-05.2008, por furto qualificado).

Anoto, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, que extrapolou o esperado pelo tipo penal em apreço, face à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, frise-se, 551 porções de cocaína, com peso bruto de 507,71g (8,77g + 498,94g) e líquido de 436,19 (7g + 429,19), conforme laudo de fls. 149/152.

Neste aspecto, inclusive, confira-se: "TJ-SP - Apelação Criminal nº 0028720-96.2014.8.26.0224; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Márcio Eid Sammarco; Origem: Comarca de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Julgamento: 06.06.2019; Publicação: 07.06.2019".

Além disso, destaco que a cocaína possui efeitos deletérios àqueles que dela fazem

uso com alta probabilidade de dependência imediata e catastrófica após a sua ingestão, bem como se apresenta extremamente nociva à sociedade como um todo, tornando-se um problema endêmico de saúde pública em todo o território nacional. Assim, pautando-se pela proporcionalidade e razoabilidade exigida, exaspero a pena-base em 1/5 (um quinto) fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, como já destacado, o réu possui condenação anterior, consoante certidão de fls. 28/30 (processo nº 1501497-47.2019, por posse irregular de arma de fogo), de modo que incide ao caso a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Presente, ainda, a atenuante da confissão, conforme previsão do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal e em consonância com a súmula 545, do STJ.

No entanto, considerando a existência de uma circunstância agravante e uma atenuante, permanece a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu não faz jus à redução prevista na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenche os requisitos legais, porque é reincidente em crime doloso.

Reforçando ainda mais o afastamento da benesse, infere-se do seu interrogatório e da certidão de fls. 28/30, que o réu também ostenta maus antecedentes.

Destarte, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não restarem atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal; o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, impedem a concessão da benesse por restar desatendido o inciso III do dispositivo legal retro mencionado.

Além do mais, não se olvida que o réu é reincidente, de modo que a concessão da benesse encontra óbice no inciso II, do artigo 44; bem como o montante de pena imposta ao acusado supera o limite disposto no inciso I, do citado artigo.

Pelas mesmas razões, desatendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena.

Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, observadas as colocações feitas por ocasião da não substituição da pena privativa, o REGIME FECHADO, único que se mostra compatível com a gravidade do delito e sua potencialidade lesiva.

Ainda quanto a fixação do regime inicial fechado, colhem-se os seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. "Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado". RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0057527-71.2011.8.26.0050; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marco Antonio Marques da Silva; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 27.06.2013 e 05.07.2013) - sem destaques no original.

"No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 990.09.042255-6; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Paulo Rossi; Origem: Comarca de Mogi das Cruzes; Julgamento e Publicação: 01.07.2009) - sem destaques no original.

"Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência

probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime prisional aberto - Provas francamente incriminadoras - Condição de usuário que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Pena que não comporta reparo. Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito - Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade - Inaplicabilidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - A competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções - Negado provimento." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0001719-19.2014.8.26.0263; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Fernando Simão; Origem: Comarca de Itai; Julgamento e Publicação: 10.09.2015 e 14.09.2015) - sem destaques no original.

"Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R\$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4º, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei nº 11.464/07). Apelo improvido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0071629-66.2012.8.26.0114; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Pinheiro Franco; Origem: Comarca de Campinas; Julgamento e Publicação: 04.07.2013 e 05.07.2013) - sem destaques no original.

E também o quanto já decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando familiares". (In RTJ 123/547).

Soma-se a tal que é de entendimento deste juízo, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os supramencionados dispositivos constitucionais e legais, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto nº 154/91, especialmente aos seus artigos 4º, "a", 6º e 7º. Atento às características do delito praticado, a quantidade de pena e regime imposto, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

No sentido exposto, o magistério de Júlio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis:

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delitosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

E, ainda, no seguinte julgado, in verbis:

"Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado". (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Por fim, ausentes nos autos informações concretas acerca da situação econômica do acusado, e considerando a declaração do réu de que estava desempregado no momento da prisão, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para CONDENAR o réu JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO, portador do RG nº 33.241.195, natural de Sorocaba/SP, nascido aos 03.06.1978, filho de Joao Antonio da Silva e Roseli Antonia Cazarin da Silva, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

CONFORME FUNDAMENTADO, NEGO O APELO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE O RÉU JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado também pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da Execução. Nestes termos a jurisprudência do E. TJSP tem se manifestado:

"(...) inaplicável, no caso, o artigo 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão." (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº0050820-50.2011.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, julgado em 25.04.2013).

"(...) Ressalta-se, ainda que o novo dispositivo, não estabeleceu que a detração devesse funcionar como alavanca automática de progressão de regime, pois esta conta com requisitos legais objetivos (tempo de prisão) e subjetivos (bom comportamento) que devem ser analisados pelo Juízo da Execução. Ademais, é preciso lembrar, ainda, que a prisão cautelar eventualmente decretada não se confunde com a prisão em regime fechado, pois esta decorre de sentença condenatória. Assim, ao juiz do conhecimento não caberá análise de requisitos subjetivos para eventual progressão porque não se trata de concessão de nenhum benefício, senão de ajuste do tempo de pena já cumprido e cujo desconto apenas será antecipado, se favoráveis as circunstâncias judiciais do réu, como já referido anteriormente." (2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº0016805-85.201.8.26.0602, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado em 22 de abril de 2013).

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

DECLARO o perdimento do numerário apreendido em favor da União, para ser revertido diretamente ao Funad, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal c.c. o artigo 63 e parágrafos, da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei, observando as benesses da gratuidade concedida ao acusado. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente e demais comunicações necessárias.

P.I.C.

Tatui, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA